



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 1941/09

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים

הנושא: הקצאת אופציות למניות בכורה תחת הוראות סעיף 102 לפקודה – הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), הקצתה בעבר לעובדיה, שאינם בעלי שליטה, כהגדרת המונח בסעיף 9(32) לפקודת מס הכנסה (להלן: "העובדים"; "הפקודה"), אופציות הניתנות למימוש למניותיה הרגילות (להלן: "האופציות הרגילות"), בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, וזאת במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון (להלן: "המסלול ההוני").
2. נכון למועד הגשת הבקשה, תוספת המימוש הנקובה באופציות הרגילות, הינה גבוהה משמעותית משווי מניות החברה.
3. הון המניות של החברה כולל, בנוסף למניות רגילות, גם מניות בכורה (Preferred Shares), מסוגים שונים, המעניקות למחזיקים בהן זכויות עודפות (להלן: "מניות הבכורה"), ובין היתר, בעת חלוקת התמורה במקרה של מכירת מניות החברה ו/או את פעילותה ו/או את כל נכסיה (להלן כל אחד מהמקרים האמורים: "EXIT").
4. לאור קשיים אליהם נקלעה החברה, ובשל סיבובי הגיוס וההשקעה הרבים שבוצעו בה בעבר, מניות הבכורה הינן בעלות עדיפות לקבלת החלק הארי של התמורה במקרה של EXIT, כך שנוצר מצב בו הזכויות הצמודות למניות הרגילות של החברה אינן מעניקות לעובדים שום חלק מהתמורה שתתקבל ב-EXIT, אלא רק במקרה, בו ה-EXIT יעשה לפי שווי גבוה ביותר של החברה, אשר אינו ריאלי והסבירות שיתרחש הינה נמוכה מאד. לפיכך, במצב דברים זה, האופציות שהוענקו לעובדי החברה הינן מעשית הינן חסרות ערך כמעט לחלוטין, ואינן משמשות עוד כתמריץ לעובדים להמשיך ולעבוד בחברה.
5. מכאן, על מנת לתמרץ את עובדי החברה להמשיך ולעבוד בחברה, בכוונת החברה לאמץ תוכנית אופציות חדשה (להלן: "התוכנית"), שתאפשר הענקת אופציות לעובדים, אשר תהיינה ניתנות למימוש למניות בכורה מסוג חדש (להלן: "אופציות חדשות" "מניות בכורה חדשות" בהתאמה), וזאת על מנת שגם העובדים ייהנו מתמורה מסוימת באם החברה תבצע EXIT גם בשווי נמוך.
6. מניות הבכורה החדשות תקנינה למחזיק בהם, בין היתר, זכות לקבל אחוז מסוים מהתמורה במקרה של EXIT (להלן: "הזכות העודפת"), יחד עם שאר בעלי מניות הבכורה בחברה.
7. יודגש, כי מניות הבכורה החדשות תקנינה זכות נוספת בעת EXIT כאמור לעיל, בנוסף לשאר הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות, ולא במקומן. כמו כן יובהר כי:
 - 7.1. מועדי ההבשלה של האופציות החדשות, אינם קשורים או מותנים, במישרין או בעקיפין, באירוע של EXIT (למעט אפשרות לאקסלרציה במקרה של EXIT).
 - 7.2. לא תהא אפשרות לבצע באופציות החדשות תמחור מחדש (Repricing) ו/או שינוי בתקופת ההבשלה (Re – Vesting), בשום שלב שהוא במהלך חייהן (למעט אפשרות לאקסלרציה במקרה של EXIT).



החטיבה המקצועית

- 7.3. במידה והאופציות החדשות/מניות הבכורה החדשות תימכרנה לצד ג', הרי שגם הרוכש יהיה זכאי לזכות העודפת הנוספת. קרי, הזכות העודפת הינה חלק בלתי נפרד מסך הזכויות המוקנות למחזיק באופציות החדשות/מניות הבכורה החדשות, לפי העניין.
- 7.4. במידה ובמועד ה- EXIT, התמורה שתשלם החברה הרוכשת תהא באמצעות מניות, ולא במזומן, הרי שהקדימות בחלוקת התמורה לבעלי מניות הבכורה החדשות תתבטא גם בקדימות בקבלת מניות החברה הרוכשת, לפי העניין.
- 7.5. יודגש כי, בהתאם לחוק החברות החל בישראל, מניות הבכורה החדשות שיתקבלו בעת מימוש האופציות החדשות, אינן מסווגות כמניות רגילות בחברה, אלא כמניות בכורה. כמו כן, יובהר כי מניות בכורה חדשות אלה אינן מסווגות בהתאם לחוק החברות בישראל, כמניות נדחות, מניות הנהלה או מניות יסוד.
- 7.6. בתוכנית ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות למניות הבכורה החדשות, שיוקצו מכוחן.
- 7.7. מניות הבכורה החדשות אינן ניתנות לפדיון.
- 7.8. הסכום שיתקבל בעת מכירת מניות הבכורה החדשות, ייקבע כאחוז מהתמורה העתידית שאינה ידועה עד למועד העסקה, והיא אינה סכום קבוע מראש.
- 7.9. הנפקת מניות הבכורה החדשות תהווה פעולה של הקצאה והגדלת ההון המונפק בחברה, במסגרת ההון הרשום של החברה.
- 7.10. הזכות העודפת אינה מקנה למי מהעובדים את הזכות לקבל מעל 10% מהתמורה העתידית, בכל סיטואציה שהיא.
- 7.11. יובהר כי הזכות העודפת אינה משנה את סיווג תוכנית האופציות לצרכים חשבונאיים, והתוכנית תמשיך להיות מסווגת כתוכנית הונית על פי: FAS123R של המוסד האמריקני לתקינה חשבונאית ו/או תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ו/או IFRS2 של המוסד לתקינה חשבונאית בינלאומיים, ולא תסווג כתוכנית התחייבותית לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על האופציות החדשות המוענקות לעובדים.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

- בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו על-ידכם בסעיף העובדות לעיל לרבות המפורטות בסעיף 4 לעיל, קרי האופציות למניות הרגילות נמצאות עמוק מחוץ לכסף, הריני לאשר את הסדר המס כדלקמן:
1. האופציות החדשות תחשבנה כעומדות בתנאי הקצאת אופציות במסלול ההוני.
 2. תנאי לאמור לעיל הוא כי התמורה עבור מכירת מניות הבכורה החדשות תועבר מצד ג' (הרוכש) ולא מהחברה ו/או ממי שמחזיק שליטה" בה.



החטיבה המקצועית

3. לעניין החלטת מיסוי זאת EXIT יחשב רק אירוע בו נמכרו הזכויות בחברה לצד ג', במישרין או באמצעות עסקת מיזוג (לא כולל הנפקה בבורסה) ו/או בוצעה עסקת נכסים שמיד בסמוך אליה (במהלך אותו הרבעון), קיבלה החברה החלטה לגבי פירוקה. למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה בו תשתלם תמורה בשל מניות בכורה חדשות, במסגרת אירוע שאינו מוגדר כאירוע EXIT, יסווג חלק התמורה העולה על התמורה המיוחסת למניה רגילה של החברה כהכנסת עבודה.

4. יובהר כי כל תמורה (לרבות תמורות מותנות, ככל ויהיו) שיקבלו העובדים ב- EXIT בגין האופציות למניות הבכורה שברשותם, מעבר ל"שווי המניה הממוצע" כפי שיקבע בעסקה, תיחשב כהכנסת עבודה. לעניין זה, "שווי המניה הממוצע" הינו הסכום המתקבל מחלוקת סך התמורה בעסקה בסך כל כמות המניות של החברה (ללא הבחנה בסוג המניות) בדילול מלא, במועד העסקה.

לדוגמא:

סך התמורה המשולמת במסגרת העסקה:	20 מליון דולר
התמורה שיקבל כל עובד בגין מניית בכורה אחת:	8 דולר
סך כמות המניות הרגילות בחברה:	500,000
סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת האופציות למניות רגילות בחברה:	2,000,000
סך כמות מניות הבכורה (מכל הסוגים) בחברה:	1,300,000
סך כמות מניות הבכורה, שהוקצו בגין המרת האופציות החדשות:	200,000

"שווי המניה הממוצע": 5 דולר. $(20,000,000 / 4,000,000 =)$

מרכיב הכנסת עבודה בגין כל מניה: 3 דולר. $(8 - 5 =)$

יובהר כי בגין מרכיב הכנסת העבודה כאמור, תותר לחברה הוצאה לצרכי מס, במועד המימוש, באותו סכום.

5. בהמשך לסעיף 4 לעיל, יובהר כי בכל מקרה סכום שישולם לעובד, מעבר לשווי מניית הבכורה שברשותו, כפי שנקבע בעסקה, יסווג כהכנסת עבודה.

6. מוסכם כי במידה והאופציות החדשות ימומשו בתקופה של עד 9 חודשים ממועד הקצאתם, תחשב התמורה כולה עבור הזכות הנוספת כהכנסת עבודה בידי העובד.

7. האופציות תהיינה על שם, ויופקדו אצל הנאמן ממועד הענקתן ועד לתום התקופה לפחות.

8. במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, יומרו האופציות החדשות למניות בכורה אותן תנפיק החברה. למען הסר ספק, יובהר כי, מניות הבכורה שיונפקו כתוצאה מהמרת האופציות החדשות, לא ירכשו, במישרין או בעקיפין, ע"י החברה או ממי שמחזיק שליטה בה.

9. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה בעתיד של מגבלת תום התקופה, הוראות למקרים בהם הון מניות החברה מורכב ממספר סוגים של מניות בכורה בעלי קדימות שונה או בעלי זכויות שונות, אופן קביעת שווי מניות בכורה, וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.